

1500416-35.2022.8.26.0320
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/05/2022
... p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
1ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500416-35.2022.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500416-35.2022.8.26.0320
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2039292/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 22949278 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 13/22/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2039292 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2039292/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
André Carlos Acosta
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ANDRÉ CARLOS ACOSTA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, supostamente, em 10 de fevereiro de 2022, por volta das 15h40min, na Avenida Frei João das Mercês, nº 724, bairro Parque Nossa Senhora das Dores II, neste município e comarca, vendeu e tinha em depósito, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 04 (quatro) porções de "crack", pesando 1,42g (um grama e quarenta e dois centigramas) e 05 (cinco) porções de "Cannabis sativa L.", popularmente conhecida como "maconha", pesando 12,79g (doze gramas e setenta e nove centigramas), para venda a consumo de terceiros, sendo que a infração penal ocorreu nas imediações de sede de entidade esportiva.

Regularmente notificado (fl. 146), o réu apresentou defesa preliminar à fl. 150.

A denúncia foi recebida em 10 de abril de 2022 (fl. 156).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública realizou considerações acerca da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante (fl. 03), do Boletim de Ocorrência (fls. 25/26), do auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), do auto de constatação preliminar (fls. 35/38), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/106), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, a testemunha Policial Civil RICARDO ALFREDO COELHO aduziu que na data dos fatos diligenciava no bairro Nossa Senhora das Dores com viatura descaracterizada, visando a filmar eventual movimentação de tráfico de entorpecentes. Quando passava pela Avenida Frei João das Mercês, visualizou um rapaz de boné e camiseta cavada em local já muito conhecido como ponto de venda de drogas. Estacionou a viatura, realizando campana, obtendo êxito em filmá-lo realizando algumas aparentes vendas de drogas, a primeira delas a um motociclista e as demais a transeuntes. Também captou imagens do suspeito pegando algo, provavelmente drogas, na vegetação rasteira do canteiro central da avenida. Acionou a equipe de apoio, que se deslocou até o local indicado, onde abordaram o réu, que trazia no bolso da bermuda a quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Dirigiu até o local onde ele buscava a droga no canteiro central, localizando 5 (cinco) pequenas porções de "maconha", além de 5 (cinco) pedras de "crack". Ao lado do local havia uma quadra de esportes e uma escola, tendo estacionado seu veículo perto dos automóveis dos professores que lecionam no estabelecimento de ensino.

Nesse exato sentido foi o depoimento do Policial Civil RAFAEL SILVA VARUZZA, o qual declarou que, no dia dos fatos, quando diligenciava com viatura descaracterizada em pontos de venda de entorpecentes do bairro Nossa Senhora das Dores, foi solicitado via celular pelo colega Ricardo para que se deslocasse até a Avenida Frei João das Mercês, próximo à quadra de esportes, onde um rapaz de boné e camiseta cavada teria sido filmado vendendo drogas. Chegando ao local, já de posse das imagens enviadas via aplicativo de mensagens "Whatsapp", abordou o rapaz, encontrando no bolso de sua bermuda a importância de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). O investigador Ricardo se dirigiu até o canteiro central da avenida, onde o suspeito havia sido filmado pegando algo no chão junto à vegetação rasteira e lá encontrou algumas

porções de “maconha” e de “crack”. Indagado, o suspeito, ora acusado, alegou inicialmente estar apenas tomando uma cerveja; todavia, ciente das filmagens e das drogas localizadas, acabou confessando a autoria do tráfico. Disse que, ao lado dos fatos, havia uma quadra de esportes.

Na delegacia, o acusado confessou que realizava o comércio espúrio de entorpecentes, por causa de dívidas de droga (fls. 07/08). Em juízo, disse que era usuário e na data dos fatos estava vendendo os entorpecentes para sustentar o vício, tendo dívidas com traficantes. Disse que a quadra de esportes estava vazia.

Note-se que a confissão do réu encontrou amparo nos demais elementos de prova amealhados no conjunto probatório destes autos, ponderando-se que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais militares, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos Policiais Militares e a própria confissão, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

No que tange à pena, em que pese respeitável orientação em sentido adverso, não é o caso de reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, “j”, do CP, porquanto ausente o nexo causal entre o cometimento do delito e a situação de pandemia, a

qual acomete todas as pessoas, indistintamente. Acerca do tema, confira-se:

Furto qualificado pelo concurso de agentes - Absolvição - Impossibilidade - Prova segura que atesta a prática criminosa pelos réus - Concurso de agentes bem evidenciado - Vítima que descreveu, sem sombra de dúvidas, a atuação de cada um dos réus - Afastamento da agravante da pandemia - Nexo causal não evidenciado - Confissão parcial de um dos réus reconhecida, sem interferência na pena por expressa vedação da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça - Tentativa bem reconhecida - Fração aplicada em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto mantido - Substituição da pena corporal por pena exclusivamente pecuniária - Suficiência ante a baixa gravidade concreta do delito - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1516694-67.2020.8.26.0228; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, por sua vez, deve prevalecer, pois, alterando-se entendimento anterior, verifica-se que se trata de circunstância objetiva, bastando que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, como forma especial de tutela de seus frequentadores, ainda que potencialmente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CRACK E COCAÍNA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - No presente caso, o magistrado, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, cocaína, com o peso aproximado de 1,3g (um grama e três decigramas), e 02 grandes pedras de crack embaladas por saco plástico pesando aproximadamente 51g (cinquenta e um gramas). In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos

princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. IV - No que se refere à causa de aumento de pena descrita no inciso III, do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, esta Corte tem o entendimento de que, "é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (HC n. 450.926/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/08/2018). V - Na hipótese, inexistente flagrante ilegalidade a ser sanada pelo writ, uma vez que o Tribunal de origem, bem consignou, in verbis: "já que a proximidade de uma quadra poliesportiva (138 metros), de um playground infantil (260 metros) e de uma unidade de ensino (425 metros), do local onde o delito foi praticado, ficou cabalmente demonstrada, pelo laudo pericial de fls. 230/232, e se é certo que a distância dessa última é superior às das demais, há que se observar que, numa pequena cidade do interior, em que os fatos ocorreram, onde a geografia urbana não é intrincada, como por exemplo na Comarca da Capital, tal torna mais fácil o acesso às drogas que eram comercializadas pelo réu, no ponto onde foi surpreendido aos frequentadores desse estabelecimento". Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. VI - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. VII - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos, e nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, pois foi preso "em imóvel desde antes conhecido da polícia por ser utilizado por traficantes para a prática do comércio espúrio" elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 583833/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação/fonte DJe 26/08/2020, g.n.)

Impende grifar que a quadra poliesportiva pode ser caracterizada como "recintos onde se realizem diversões de qualquer natureza", expressão utilizada no artigo 40, inciso III, e, ainda que assim não o fosse, o policial Ricardo aduziu que também havia nas proximidades uma escola, o que basta para a configuração da majorante.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes (fls. 40/48), logo fixo a pena-base acima do mínimo, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 40/48) compensa-se com a atenuante da confissão espontânea. Descabida a alegação de incidência da atenuante genérica, a teor do artigo 66, do CP, não sendo relevante a ocorrência da situação de pandemia ou o próprio vício do réu, circunstâncias que em nada influenciam no

grau de culpabilidade da conduta.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, nos termos acima delineados, de modo que majoro a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que se torna definitiva, ausentes outros elementos de modificação. Deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, §4º, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, não fazendo jus à benesse, por expressa disposição legal, ainda que não considerada grande a quantidade de drogas apreendidas.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, tendo em vista o montante de pena imposta, a reincidência, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena, a reincidência, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, o réu ANDRÉ CARLOS ACOSTA, devidamente qualificado, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial, a reincidência, os maus antecedentes e a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros delitos violentos e causando o vício de inúmeras pessoas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido. Oficie-se.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA